

1500228-44.2019.8.26.0612

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... - Voto nº 29898 - J 9 101/498).

"TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500228-44.2019.8.26.0612 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500228-44.2019.8.26.0612

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2312437/2019 - DEL.POL.GUARIBA, 8219397 - DEL.POL.GUARIBA, 1507/19/434 - DEL.POL.GUARIBA, 2312437 - DEL.POL.GUARIBA, 1507/19/434 - DEL.POL.GUARIBA, 2312437 - DEL.POL.GUARIBA, 1507/19/434 - DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO RAFAEL DE ALMEIDA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou GUSTAVO RAFAEL DE ALMEIDA SOUZA como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 25 de outubro de 2019, por volta das 15h30min., na Avenida Ernesto de Angelis, em frente ao número 10, estrada de terra, Jardim Paulistano, nesta cidade e Comarca de Guariba, com unidade de desígnios com o adolescente Eduardo Rogério de Souza Rinaldi, o denunciado trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 35 eppendorfs de cocaína e 01 trouxinha de maconha, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal. Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado teria corrompido o adolescente Eduardo Rogério de Souza Rinaldi, nascido em 27.12.2001, menor de 18 anos na data dos fatos, com ele

praticando infrações penais.

O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação (fls. 152/153). A denúncia foi recebida em 01 de junho de 2021.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e Eduardo, como testemunha do Juízo, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia com a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. A Defesa, por sua vez, pela ausência da comprovação de atos de venda, pugnou pela desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito foi provada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelos laudos periciais de fls. 80/91, bem como pela prova oral colhida em audiência.

O policial Leandro Costa, em Juízo, afirmou que no dia dos fatos o acusado e o menor estavam em fuga depois que foram abordados. Disse que não viu quem realmente dispensou os entorpecentes. Esclareceu que as drogas foram encontradas na direção em que Gustavo se evadiu.

O policial Antonio Wanderley Feitosa, em Juízo, depôs no mesmo sentido da testemunha acima, afirmando que parte dos entorpecentes foram encontrados no caminho da fuga do acusado.

A testemunha Eduardo Rogério (adolescente), em Juízo, afirmou que ele chamou o acusado para comprar entorpecentes. Disse que estavam indo embora com as drogas após a compra quando uma viatura chegou. Afirmou que foram abordados e surpreendidos na posse dos entorpecentes. Disse que admitiu para os policiais que as drogas eram dele e que estavam na mão do acusado porque estava pilotando a moto. Em seu interrogatório, o acusado disse que foi até a cidade de Guariba com o menor para comprar entorpecentes para consumo próprio. Disse que a moto era do menor.

Pois bem. Eis o teor da prova oral produzida.

Ora, não se trata simplesmente de desmerecer a versão do acusado.

É que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Os policiais militares prestaram depoimentos seguros e coesos, sendo que, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

O simples fato de estas testemunhas pertencerem aos quadros da polícia e terem participado das diligências que culminaram com a prisão do acusado não os torna indignos de fé, sobretudo porque não há qualquer indício de que tenham prestado seus depoimentos com o fito de legitimar a conduta funcional, de cuja regularidade, aliás, não há razão para se duvidar.

Não há razão para a absolvição quando as únicas testemunhas de acusação são os próprios investigadores ou policiais militares que cuidaram do caso nas fases extrajudiciais, já que não existe qualquer impedimento nesta dupla atuação. Ora, a partir do momento em que o Estado legitimou a investidura da Polícia Civil e Militar no combate à criminalidade, pode e deve o Estado-juiz conceder-lhes o mesmo crédito inicialmente depositado quando narram suas atividades, já que cientes de seu compromisso de dizer a verdade, sujeitos às penas do crime de falso testemunho ou de denúncia caluniosa, exatamente como os demais cidadãos. Neste sentido:

"A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação" (TJSP, Apelação Criminal nº. 128.275-3/9 - Rel. Des. Canguçu de Almeida)"

Quanto à afirmação de que é mero usuário, a forma com que as drogas foram apreendidas não se coaduna com a situação de quem pretendia consumi-las para saciar

seu vício. Assim, a versão judicial do réu de que as drogas apreendidas seriam destinada a seu consumo pessoal, mostrou-se isolada. Mas não é só. Ainda que, eventualmente, fosse o acusado usuário de entorpecentes, a configuração do crime de tráfico continuaria possível, eis que muitos traficantes se utilizam deste expediente para sustentar o próprio vício. Nesse sentido:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4ª Câmara de Direito Criminal Apelação nº 0000248-23.2016.8.26.0610 - Voto nº 29898 - J 9 101/498).

"TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admite várias condutas. Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de entorpecente tendo em vista que o recorrente não comprovou, na fase instrutória, a destinação da droga para o uso pessoal, pelo contrário, ficaram evidenciados os atos de traficância pela quantidade e a forma em que a droga foi encontrada (vinte pedras de 'crack' e um pacote de cocaína). Mesmo que consideremos o fato do acusado ser usuário de 'crack' e cocaína, tal condição não afasta a qualificação de traficante, ocorrendo a absorção do delito de porte para uso pelo de tráfico." (Apelação Criminal Nº 1.0625.04.037027-6/001 - Comarca De São João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des. Sérgio Braga.j.22.05.2005)"

De outra parte, ainda que os policiais não tenham presenciado os réus em atitude típica de traficância, tal circunstância não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal. Isso porque a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 consiste em um tipo misto alternativo e tem como um de seus núcleos "trazer consigo, ou guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, pelas circunstâncias, está claro o propósito de tráfico, tanto pela quantidade quanto pela forma de acondicionamento dos entorpecentes.

Neste contexto, havendo, nos autos, seguros elementos de que o acusado trazia consigo expressiva quantidade de substância entorpecente, ele deve ser responsabilizado pelo delito descrito no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

No que tange o crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, merece ser afastada a acusação. No caso, não há prova suficiente de que o adolescente tenha sido corrompido por influência do réu ou que este tenha facilitado a corrupção dele. Não há nenhuma evidência no processo a indicar que a conduta ilícita do menor tenha resultado de persuasão ou facilitação levada a cabo pelo réu, daí a improcedência da denúncia neste ponto.

Colocadas tais ponderações, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, ante inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a menoridade relativa do acusado, no entanto, deixo de atenuar a pena em razão da fixação no mínimo legal na primeira fase.

Não há causas de aumento da pena.

Os requisitos (cumulativos) para aplicação da causa de diminuição estão taxativamente previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: ser a agente primário, detentor de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. O referido dispositivo prevê a possibilidade do Juiz (leia-se: poder-dever) em reduzir de 1/6 a 2/3 a pena fixada quando presentes os quatro requisitos cumulativos acima elencados, sem, contudo, estabelecer parâmetros para o exato estabelecimento deste quantum pelo magistrado. Falhou o legislador. Por tais razões compete a doutrina hodierna e a jurisprudência o interpretarem à luz das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse diapasão é que, no caso em exame há de ser levada em conta a quantidade substâncias apreendidas. Parece-me razoável asseverar que quanto maior a

quantidade, mais variados os tipos e o campo de comercialização deles, menor a diminuição da pena. É nesse sentido, inclusive, o posicionamento da 5ª Turma do C. STJ (HC 136.618/MG, Min. Laurita Vaz, v.u. 01.06.10) e da 5ª Câmara Criminal do E. TJSP (Ap.990.09.170.228-5 - Des. Rel. Marcos Zanuzzi, v.u. j. 10.12.09). Nesta esteira, atento a natureza e quantidade dos entorpecentes, é que a redução deverá ser feita na proporção de 1/4 (um quarto), perfazendo o total de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva do réu em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Tofoli. Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 1.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

Desta forma, ainda em razão da natureza da droga, bem como das circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, consoante o art. 33, § 2º, do Código Penal.

Altero meu posicionamento anterior a fim de conceder ao réu, ante o teor da pena aplicada, primariedade e demais requisitos objetivos, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (1) prestação de serviços à comunidade pelo tempo de condenação e (2) entrega de bens a entidades do juízo no importe de 1 salário mínimo, como de praxe nesta comarca. Maiores detalhes sobre a forma de cumprimento destas penas alternativas serão apontados pelo juízo das execuções.

Sem detração ou progressão neste ato, tanto porque ainda não cumpridos o requisito objetivo (temporal), quanto pelo fato de que ausentes elementos para análise do requisito subjetivo, devendo tal matéria ser analisada pelo juízo competente, ou seja, o das execuções - aliás, como vem entendendo a jurisprudência do E. TJ/SP. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido na ação penal e CONDENO GUSTAVO RAFAEL DE ALMEIDA SOUZA como incurso no artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, a qual substituo por duas restritivas de direito, consistentes em (1) prestação de serviços à comunidade pelo tempo de condenação e (2) entrega de bens a entidades do juízo no importe de 1 salário mínimo, como de praxe nesta comarca, bem como absolvo o acusado do crime tipificado no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Concedo o apelo em liberdade.

Determino a perda do dinheiro e demais bens apreendidos em favor da União. Proceda-se como de praxe.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que é beneficiário da gratuidade de justiça (advogado nomeado em razão do convênio entre a OAB/SP e a DPE/SP). Expeça-se certidão de honorários, nos termos máximos previstos na tabela de regência.

P.I.C.

Guariba, 18 de julho de 2022.